

第4節 共犯と身分

刑法
No167

H18-4

(配点: 3)

月	日
月	日

次の【記述】中のアないしウの《 》内に後記の【見解】ⅠないしⅢから適切なものを、また、同【記述】中の①から⑤までの（ ）内に後記の【語句群】から適切な語句を、それぞれ入れた場合、《 》及び（ ）内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

「刑法第65条第1項及び第2項の解釈について、共犯の従属性を徹底する立場から、《ア》があるが、これに対しては、(①)という批判がある。また、『違法の連帯性、責任の個別性』という原則を強調する立場から、《イ》があるが、これに対しては、(②)という批判がある。さらに、法文の文理に忠実に解釈をする立場から、《ウ》があり、これが判例の考え方であるが、これに対しては、(③)という批判がある。『賭博の非常習者である甲が、常習者である乙と共同して賭博を実行した。』という事例の甲の罪責を検討すると、《ウ》からは、(④)という結論になるのに対し、《ア》からは、(⑤)という結論になる。《イ》からは、常習賭博罪という身分犯の性格をどのように考えるかによって結論が変わることになる。」

【見解】

- Ⅰ. 「同条第1項は真正身分犯についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯についての規定である。」とする見解
- Ⅱ. 「同条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である。」とする見解
- Ⅲ. 「同条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。」とする見解

【語句群】

- a. 違法身分と責任身分を区別することは困難であり、また、違法身分と責任身分が混合している身分犯もある
 - b. 真正身分犯が身分を連带的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠を明らかにしていない
 - c. 犯罪の成立と科刑が分離されることになる
 - d. 単純賭博罪の共同正犯が成立し、科刑も単純賭博罪の刑による
 - e. 常習賭博罪の共同正犯が成立し、科刑も常習賭博罪の刑による
 - f. 常習賭博罪の共同正犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による
- 1. アⅠ-②c⑤d 2. アⅢ-①c④e 3. イⅡ-①b⑤f
 - 4. イⅢ-③b④f 5. ウⅠ-②a④d

(参照条文) 刑法

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

No167

共犯と身分

正答率

H18-4

正解

5

70%

《 》には順に、ア＝Ⅲ、イ＝Ⅱ、ウ＝Ⅰと入り、()には順に、①＝c、②＝a、③＝b、④＝d、⑤＝fと入り、したがって、正解は肢5となる。

【見解の穴埋めについて】

ア Ⅲ

「共犯の従属性を徹底する立場から」という記述から、アには共犯の従属性を徹底させる立場の見解が入ることがわかる。この点、見解Ⅲの「同条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。」とする見解は、非身分者についても身分犯の共犯が成立することを、1項で「共犯とする」と規定したのであり、2項は1項で共犯とされたもののうち非身分者の科刑について「通常の刑を科する」と規定したとする。これは、共犯の従属性を徹底させようとする立場で、正犯と共犯に同一の罪が「成立する」とし、しかも1項と2項が逆行しているのを矛盾なく説明しようとしたものである。したがって、アには、見解Ⅲが入る。

イ Ⅱ

「『違法の連帯性、責任の個性性』という原則を強調する立場から」という記述から、イには違法の連帯性・責任の個性性を強調する立場の見解が入ることがわかる。この点、見解Ⅱの「同条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である。」とする見解は、65条が「違法は連帯的に、責任は個別的に」という原理に基づく規定であり、1項は身分が行為の違法性を規制する要素（違法身分）となっている場合に違法の連帯性を、2項は身分が行為の責任を規制する要素（責任身分）となっている場合に責任の個性性を定めた規定と解している。したがって、イには、見解Ⅱが入る。

ウ Ⅰ

「法文の文理に忠実に解釈をする立場から」という記述、及び「これが判例の考え方である」という記述から、ウには法文の文理に忠実に解釈をする立場で、判例の採る見解が入ることがわかる。この点、見解Ⅰの「同条1項は真正身分犯についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯についての規定である。」とする見解は、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」（65条1項）、「身分によって特に刑の軽重があるとき」（同条2項）という法文の文理どおりに、65条1項は構成的身分の連帯作用を、同条2項は加減的身分の個別作用を定めたものとする。判例（最判昭31.5.24等）も、かかる見解を採用している。したがって、ウには、見解Ⅰが入る。

【語句群の穴埋めについて】

① c

「《ア》があるが、これに対しては、(①)という批判がある。」という記述から、①には、アに入る見解Ⅲに対する批判が入ることがわかる。この点、見解Ⅲの「同条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。」とする見解によると、例えば、非身分者が業務上墮胎罪（214条）を教唆した場合に、1項によって業務上墮胎罪の教唆犯が成立することになるが、刑は同意墮胎罪（213条）によることになり、犯罪の成立とそれに科される刑とが分離されることになると批判される。したがって、①には、「c. 犯罪の成立と科刑が分離されることになる」が入る。

② a

「『イ』があるが、これに対しては、(②)という批判がある。」という記述から、②には、イに入る見解Ⅱに対する批判が入ることがわかる。この点、見解Ⅱは「同条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である。」というように、違法身分と責任身分とが区別できることを前提としている。しかし、違法身分犯と責任身分犯とを区別することはかなり困難であり(例・212条の堕胎罪)、また、違法身分と責任身分が混合している身分犯もあり(例・202条の同意殺人罪)、このような場合にこの説は65条の解釈としては無理であると批判される。したがって、②には、「a. 違法身分と責任身分を区別することは困難であり、また、違法身分と責任身分が混合している身分犯もある」が入る。

③ b

「『ウ』があり、これが判例の考え方であるが、これに対しては、(③)という批判がある。」という記述から、③には、ウに入る見解Ⅰに対する批判が入ることがわかる。この点、見解Ⅰの「同条第1項は真正身分犯についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯についての規定である。」とする見解は、1項は真正身分犯(構成的身分犯)、2項は不真正身分犯(加減的身分犯)に関する規定と解する。しかし、なぜ、真正身分犯は身分がない者に連带的に作用し、不真正身分犯は連带的に作用しないかについて十分な説明が与えられていないと批判されている。したがって、③には「b. 真正身分犯が身分を連带的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠を明らかにしていない」が入る。

④ d

「『賭博の非常習者である甲が、常習者である乙と共同して賭博を実行した。』という事例の甲の罪責を検討すると、『ウ』からは、(④)という結論になる」との記述から、④にはウに入る見解Ⅰに依拠した場合の甲の罪責が入ることとなる。この点、「共同した」とあることから本事例では甲に共同正犯が成立することとなるが、共同正犯の場合であっても、判例(大判昭9.11.20等)・通説は65条の適用を肯定する。常習賭博罪(186条1項)は、行為者の常習性という身分により単純賭博罪の刑を加重する加減的身分犯である。そうすると、見解Ⅰによれば、不真正身分犯として、65条2項によって成立・科刑を決することとなる。同条項は、「身分のない者には通常の刑を科する」とあることから、非身分者には単純賭博罪が成立し、同罪の刑によることとなる。したがって、④には、「d. 単純賭博罪の共同正犯が成立し、科刑も単純賭博罪の刑による」が入る。

⑤ f

「『ア』からは、(⑤)という結論になる」との記述から、⑤にはアに入る見解Ⅲに依拠した場合の甲の罪責が入ることとなる。この点、見解Ⅲによれば、加減的身分犯は不真正身分犯として、65条1項によって成立する犯罪が定められ、2項によって科刑が定められる。そうすると、1項が「身分のない者であっても、共犯とする」とあることから、甲には身分犯たる常習賭博罪が成立し、2項に「身分のない者には通常の刑を科する」とあることから単純賭博罪の刑が科されることになる。したがって、⑤には、「f. 常習賭博罪の共同正犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による」が入る。